EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PRECLARO DOUTOR JOAQUIM BARBOSA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – ABRAFIX, entidade de abrangência nacional, representante das empresas concessionárias do serviço de telefonia na modalidade fixo comutado (STFC), com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco F, Sala 820, na cidade de Brasília, Distrito Federal, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.230.715/0001-29 (**Doc. 01**), por intermédio de seus advogados (**Doc. 02**), vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas *"a"* e *"p"*, e 103, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos da Lei nº 9.868/99, propor a presente

Ação Direta de Inconstitucionalidade

(com pedido de concessão de medida cautelar)

em face do **artigo 17-B da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, acrescido pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012**, sancionada pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República, e publicada no Diário Oficial da União de 10 de julho de 2012, pelas razões fáticas e jurídicas adiante expendidas.

I – DO DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL ORA IMPUGNADO POR EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade volta-se contra o artigo 17-B da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), acrescido pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012 (**Doc. 03**), *in verbis:*

> "Art. 17-B. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, exclusivamente, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, **pelas empresas telefônicas**, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito" – grifou-se.

Pois bem. Como já se evidencia à primeira vista, o dispositivo ora impugnado revela-se materialmente inconstitucional por patente violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, uma vez que claramente faculta às autoridades policiais e aos órgãos ministeriais afastar *sponte propria*, isto é, *"independentemente de autorização judicial"*, o sigilo constitucionalmente assegurado aos dados cadastrais privados dos usuários das empresas de telefonia.

Assim, conforme se passará a demonstrar, o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 17-B da Lei nº 9.613/98 por este Egrégio Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, sob pena de submeter as operadoras de telefonia associadas à Autora ao cumprimento de obrigação manifestamente inconstitucional, eis que, ao assim agir, estarão afrontando gravemente o direito à privacidade de seus usuários, direito fundamental este cuja relativização somente pode ser admitida em nosso ordenamento jurídico por órgão imparcial e independente por excelência, a saber, o Poder Judiciário, mediante ordem prévia, específica e fundamentada em cada caso concreto.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

Nos termos do artigo 2º de seu Estatuto Social, a Autora é **associação representativa das empresas concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)**, cuja atuação é balizada pelos contratos de concessão firmados junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

A Autora conta ainda com **atuação em âmbito nacional**, sendo fato notório a efetiva prestação de serviços de telecomunicações por suas associadas em todos os rincões do território nacional, o que pode ser claramente demonstrado, a título exemplificativo, pela tabela anexa elaborada pela ANATEL contendo a Participação no Mercado das Prestadoras Fixas por Código Nacional[1] (**Doc. 04**).

Ademais, certo é que a legitimidade ativa *ad causam* da Autora para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade já foi **expressamente reconhecida pelo Plenário dessa Egrégia Corte** no julgamento das ADI 4.369 MC-REF/SP (Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 03.05.2011), ADI 4.603 MC/RN (Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.03.2012) e ADI 4.478/PA (Pleno, rel. Min. Ayres Britto, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2011), não remanescendo, portanto, quaisquer dúvidas no tocante a esse entendimento. Nesse sentido, oportuno destacar esclarecedor excerto do Acórdão proferido no bojo da ADI 4.478/PA:

> "**Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela ABRAFIX – Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado**, contra a Lei nº 1.336, de 20 de maio de 2009, do Estado do Amapá. [...] Antes desse enfrentamento de mérito, porém, devo me pronunciar sobre a questão preliminar da legitimidade da requerente para, justamente, a propositura da presente ADI. Fazendo-o, **sou pelo reconhecimento de tal legitimidade ativa *ad causam*, na linha da decisão mo-**

[1] Disponível em: http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=278740&pub=original&filtro=1&documentoPath=278740.pdf. Consulta em 06.11.2012.

nocrática do Ministro Gilmar Mendes, no exercício da presidência deste Supremo Tribunal Federal, que assim se pronunciou: "*a requerente parece ser legitimada para a propositura desta ação. Da leitura do estatuto social da empresa, verifica-se que constitui associação de abrangência nacional que representa as concessionárias de serviço telefônico fixo comutado, constando, entre as suas associadas, empresas que prestam serviço em todo o território brasileiro*" (ADI-MC 4369, Ministro Gilmar Mendes, no exercício da Presidência). Além disso, também entendo presente o requisito da pertinência temática entre o objeto desta ação de natureza abstrata e as atividades desempenhadas pela autora".

Outrossim, como visto, a Autora preenche o requisito da **pertinência temática**, sendo evidente a correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação.

Com efeito, segundo preconiza o ilustre Professor Luís Roberto Barroso, para que se possa falar em pertinência temática "*é preciso que haja uma relação lógica entre a questão versada na lei ou ato normativo a ser impugnado e os objetivos sociais da entidade requerente. Vale dizer: a norma contestada deverá repercutir direta ou indiretamente sobre a atividade profissional ou econômica da classe envolvida, ainda que só parte dela seja atingida*"[2].

No caso presente, o dispositivo impugnado subverte importantíssimo postulado constitucional que visa a garantir a privacidade dos usuários dos serviços de telecomunicações, impondo claramente às associadas da Autora verdadeira violação do sigilo imanente aos dados de cadastro que são constitucional e legalmente obrigadas a preservar, para que sejam fornecidos, independentemente de qualquer apreciação judicial, aos órgãos diretamente investidos da persecução penal.

[2] *O controle de constitucionalidade no direito brasileiro*. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2006, p. 146 e 147

Logo, há perfeita correlação entre as normas ora submetidas ao controle abstrato de constitucionalidade e os objetivos e finalidades da associação Autora, tal qual disposto no artigo 2º de seu Estatuto Social, *in verbis:*

> "**Art. 2° -** A ABRAFIX tem por finalidade promover, defender e administrar os interesses comuns das empresas concessionárias do serviço de telefonia na modalidade fixo comutado, tendo como objetivo principal a representação institucional de suas associadas perante as demais entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, podendo, para tanto:
> I. realizar, patrocinar e promover a defesa dos interesses comuns de suas associadas;
> (...)
> VI. promover a defesa da livre concorrência e dos princípios da ordem econômica no setor de telecomunicações, em especial no âmbito do serviço telefônico fixo comutado;
> (...)
> VIII. representar perante os poderes constituídos, inclusive podendo propor as ações judiciais que se fizerem necessárias para evitar lesão aos direitos comuns de suas associadas.

Assim, estando a Autora legitimada na forma do artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, e sendo claramente perceptível a direta repercussão do artigo impugnado na esfera jurídica de suas associadas, passa-se à exposição dos fundamentos jurídicos que subsidiam a pretendida declaração de inconstitucionalidade.

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE

Explica Paulo Bonavides que a *"Constituição é basicamente unidade, unidade que repousa sobre princípios: os princípios constitucionais"*. Esses princípios, aduz o

eminente jurista, *"não só exprimem determinados valores essenciais – valores políticos ou ideológicos – senão que informam e perpassam toda a ordem constitucional, imprimindo assim ao sistema sua feição particular, identificável, inconfundível, sem a qual a Constituição seria um corpo sem vida, de reconhecimento duvidoso, se não impossível"*.[3]

À luz dessa concepção, é lícito expressar que o sistema jurídico define-se, assim, como uma verdadeira ordem axiológica de princípios jurídicos com função ordenadora, que lhe atribuem estrutura harmônica e coerência interna, e cujo escopo primordial é a salvaguarda de seus valores mais fundamentais.

Assentada nessa premissa, a Constituição de 1988 buscou, como cediço, consolidar um constitucionalismo concretizador dos direitos fundamentais, de modo a lhes conferir imediata e máxima efetividade. Esse princípio operativo – o da máxima efetividade – intenta, pois, assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental, tornando-os diretamente aplicáveis pelos três Poderes da República, que devem por eles efetivamente zelar no exercício de seus misteres, de modo que, na sapiente expressão de J. J. Gomes Canotilho, *"no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que* [lhes] *reconheça maior eficácia*"[4].

Nesse sentido, parece evidente que os direitos fundamentais não se limitam, como outrora sugeriam os teóricos, a uma vertente puramente subjetiva, que consubstancia o poder conferido a cada pessoa de fazer valer, positivamente, a proteção que o constituinte lhe concedeu, evitando, com isso, agressões infundadas a seus direitos individuais; mas também assumem uma perspectiva objetiva, verdadeira limitação à ingerência do Estado sobre a esfera jurídica individual, impedindo, por meio de normas de competência negativa, que se exerçam, indiscriminadamente, atividades legislativas ou executivas tendentes a obliterar esses direitos.

Aliás, é justamente dessa dimensão jurídico-objetiva dos direitos fundamentais que decorre o conceito de eficácia irradiante, que se traduz na garantia de que a produção executiva e legislativa e a aplicação judicial das normas jurídicas encon-

[3] *Curso de direito constitucional.* 4ª ed. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 110.
[4] *Direito constitucional e teoria da constituição.* 6ª ed. Coimbra, Almedina, p. 227.

tram-se necessariamente condicionadas à observância daqueles valores constitucionais fundamentais sem os quais não é possível ver preservados os direitos essenciais da pessoa humana. Nesse sentido, é a lição de Daniel Sarmento, que afirma que *"a eficácia irradiante enseja a 'humanização' da ordem jurídica, ao exigir que todas as suas normas sejam, no momento de aplicação, reexaminadas pelo aplicador do direito com novas lentes, que terão as cores da dignidade humana, da igualdade substantiva e da justiça social, impressas no tecido constitucional*"[5].

Tem-se, pois, a título de primeira conclusão, que os direitos fundamentais possuem verdadeira dimensão principiológica, eis que, como visto, consubstanciam vetores axiológicos fundamentais que o Estado pretende (e deve) implementar por meio da ordem jurídica.

Contudo, vale ressaltar que não se pretende aqui sustentar serem esses direitos absolutos. Como princípios que são, os direitos fundamentais, com efeito, estão passíveis de relativizações, conforme se denota do magistério de Alexandre de Moraes: *"Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas)*"[6].

O ponto nodal, porém, está em como fazer conviver diferentes vetores constitucionais em conflito. Em resposta, Robert Alexy, ao analisar a sentença proferida pelo Tribunal Constitucional Federal alemão no caso Lüth[7], em 1958, explica as três ideias que fundamentaram raciocínio que se aplica claramente ao caso concreto, no sentido de que, sempre que a aplicação de uma norma jurídica conduzir à limitação de um direito fundamental, deve ter lugar uma ponderação judicial dos princípios constitucionais colidentes, *in verbis: "A sentença-Lüth une três ideias, que enformaram fundamentalmente o Direito Constitucional alemão. A primeira é que a garantia jurídico-constitucional de direitos individuais não se*

[5] *Direitos fundamentais e relações privadas*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008, p. 144.
[6] *Direito constitucional*. 15ª ed. São Paulo, Atlas, 2004, p. 62-63.
[7] Conta-nos Alexy que Lüth havia conclamado proprietários de cinema e distribuidores de filmes para boicotarem as películas de Veit Harlan produzidas após 1945, eis que fora este o mais proeminente diretor de filmes nazistas, a exemplo do título "Judeu Doce", principal veículo cinematográfico da propaganda nacional-socialista antisemita. Diante disso, o Tribunal de Segunda Instância de Hamburgo condenou Lüth a omitir a chamada ao boicote, sob o fundamento de que tal conduta infringiria a concepção de direito e de costumes do povo alemão. O Tribunal Constitucional Federal, porém, não obstante isso, entendeu deveria ser dada primazia ao princípio da liberdade de opinião, revertendo, pois, a decisão em favor de Lüth.

esgota em uma garantia de direito de defesa do cidadão clássico contra o Estado. Os direitos fundamentais personificam, como diz o tribunal constitucional federal, 'também um ordenamento de valores objetivos'. (...) A segunda ideia, estreitamente unida com a primeira, é que os valores jurídico-fundamentais ou princípios valem não somente para a relação entre o estado e o cidadão, mas muito além disso 'para todos os âmbitos do direito'. Com isso produz-se um 'efeito de irradiação' dos direitos fundamentais sobre o sistema jurídico todo. Direitos fundamentais tornam-se ubiquitários. A terceira ideia resulta da estrutura dos valores e princípios. Valores como princípios são propensos a colidir. Uma colisão de princípios somente por ponderação pode ser resolvida"[8].

Assim, resta claro que toda restrição a direitos fundamentais – a fim de assegurar sua própria preservação – deve sofrer um rigoroso exame constitucional pelo Poder Judiciário, a exigir a demonstração, à luz de critérios de proporcionalidade, de que a limitação no caso concreto (nunca em abstrato) se justifica diante de um interesse mais relevante. É por essa razão que sustenta Daniel Sarmento ser o princípio da proporcionalidade *"uma poderosa ferramenta para aferição da conformidade das leis e dos atos administrativos como os ditames da razão e da justiça*"[9].

Nossa jurisprudência constitucional trilha o mesmo entendimento, conforme aduz com maestria o Preclaro Ministro Celso de Mello:

> *"Com a evolução do sistema de tutela constitucional das liberdades públicas, dilataram-se os espaços de conflito em cujo âmbito antagonizam-se, em função de situações concretas emergentes, posições jurídicas revestidas de igual carga de positividade normativa.*
>
> *Vários podem ser, dentro desse contexto excepcional de conflituosidade, os critérios hermenêuticos destinados à solução das colisões de direitos, que vão desde o estabelecimento de uma ordem hierárquica pertinente aos valores constitucionais tutelados, passando pelo reconhecimento do maior ou menor grau de fundamentalidade dos bens jurídicos em posição*

[8] Direitos fundamentais, ponderação e racionalidade. *In* Doutrinas Essenciais. Direito Constitucional. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 724.
[9] *A ponderação de interesses na constituição federal.* 1ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2002, p. 77.

de antagonismo, ***até a consagração de um processo que, privilegiando a unidade e a supremacia da Constituição, viabilize – a partir da ações 'de um critério de proporcionalidade na distribuição dos custos do conflito' (...) – a harmoniosa composição dos direitos em situação de colidência****"* (STF, Tribunal Pleno, RE 389.808/PR, DJe 09.05.2011) – grifou-se.

Pois bem. O artigo 17-B da Lei nº 9.613/98, incluído pela Lei nº 12.683/12, ao subtrair do Judiciário seu poder-dever de examinar a necessidade, a razoabilidade e a justificação das restrições a direitos fundamentais, transferindo essa prerrogativa aos órgãos intimamente envolvidos nos procedimentos de apuração criminal, claramente colocou em rota de colisão o direito à privacidade dos usuários dos serviços de telecomunicações, consagrado no artigo 5º, inciso X, da CF/88, e o interesse estatal na persecução penal, sobrepujando este àquele, indistintamente, abstratamente, o que não se reputa minimamente admissível.

Note-se, inclusive, embora difícil de crer, que fora indiscutivelmente essa a *mens legislatoris*, por mais apartada que fosse dos mais comezinhos preceitos fundamentais. Com efeito, quando da avaliação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal do projeto (PLS nº 209/2003) que posteriormente deu origem à Lei nº 12.683/12, consignou o ilustre relator, o Senador Jarbas Vasconcellos, ao apreciar o capítulo das "Disposições Gerais", no qual se encontra inserido o artigo impugnado, que "*o PLS traz dispositivos que* ***facilitam a investigação*** *do crime de lavagem de dinheiro, contribuindo para um* ***resultado mais eficiente****: estabelece a forma como as informações sigilosas regularmente requeridas deverão ser apresentadas pelas entidades responsáveis e especifica a que tipos de informações cadastrais a autoridade policial e o Ministério Público poderão ter acesso* ***sem a necessidade de autorização judicial****, reforçando o que a Lei Complementar nº 105, de 2001, prescreve*" (grifou-se).

Evidente, portanto, o desejo do legislador ordinário de, sob argumento simplista de apurar-se eventual criminalidade econômica, afastar valores funda-

mentais à ordem jurídica, de extração constitucional, invadindo a esfera de proteção do cidadão, particularmente dos usuários dos serviços de telecomunicações, para romper, via de regra, e sem qualquer ponderação ou motivação, com o sigilo de dados pessoais.

Nesse passo, e aproveitando o ensejo da menção à legislação complementar que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, é imprescindível trazer à colação os fundamentos decisórios suscitados por essa Egrégia Corte Suprema nos autos do Recurso Extraordinário 389.808/PR, no bojo do qual se discutia a possibilidade de os órgãos da administração tributária afastarem, *ex propria auctoritate*, independentemente de prévio pronunciamento judicial, o sigilo bancário dos contribuintes.

Confira-se a perficiente ementa:

> *"SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal.* ***SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte****"* (STF, Tribunal Pleno, RE 389.808/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 09.05.2011) – grifou-se.

Dentre os valorosos votos proferidos pelos eminentes julgadores no caso em comento, confira-se especial destaque àquele elaborado pelo eminente Ministro Celso de Mello, que deslinda perfeitamente a *quaestio juris:*

"Na realidade, a circunstância de a administração estatal achar-se investida de poderes excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária não a exonera do dever de observar, para efeito do correto desempenho de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e pelas leis da República, sob pena de os órgãos governamentais incidirem em ***frontal desrespeito às garantias constitucionalmente asseguradas aos cidadãos em geral*** *e aos contribuintes, em particular.*

(...)

Não se pode ignorar que o ***direito à intimidade (e, também, à privacidade)*** *– que representa importante manifestação dos direitos da personalidade – qualifica-se como expressiva prerrogativa de ordem jurídica que* ***consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada****.*

(...)

Por isso mesmo, ***a transposição arbitrária, para o domínio público, de questões meramente pessoais****, sem qualquer reflexo no plano dos interesses sociais, tem o significado de grave transgressão ao postulado constitucional que protege o direito à intimidade e à privacidade (MS 23.669-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.), pois este, na abrangência de seu alcance,* ***representa o 'direito de excluir, do conhecimento de terceiros, aquilo que diz respeito ao modo de ser da vida privada' (Hannah Arendt)****.*

(...)

A relevância do direito ao sigilo bancário impõe, por isso mesmo, cautela e prudência ao Poder Judiciário na determinação da ruptura da esfera de privacidade individual que o ordenamento jurídico, em norma de salvaguarda, pretendeu submeter à cláusula tutelar de reserva constitucional (CF, art. 5º, X)" – grifou-se.

De fato, o direito ao sigilo que alberga os dados pessoais dos cidadãos, sejam eles de natureza bancária, sejam respeitantes a cadastros privados, por sua preponderância axiológica, eis que consectário do direito constitucional à intimidade e à privacidade, somente pode ser afastado – providência extraordinária que é – mediante exame prudente e cauteloso de órgão investido de jurisdição, equidistante por excelência, e desde que, nas palavras do ilustre decano desse Supremo Tribunal, revele-se *"imprescindível a existência de* ***justa causa provável****, vale dizer, de fundada suspeita quanto à ocorrência de fato cuja apuração resulte exigida pelo interesse público"* (grifou-se), a ser verificada em cada caso concreto, à luz de critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade

Não há como se admitir a possibilidade de agentes do Estado devassarem indiscriminadamente o círculo fundamental de proteção que logrou a Constituição Federal atribuir aos cidadãos, sob genéricas justificativas de interesse público (ao Estado, todo interesse é público, afinal), sem, portanto, uma *justa causa provável*, aferível única e exclusivamente à luz de caso posto, cujo juízo de ponderação precisa ser expresso, motivado, pois a regra, como visto, é a observância dos direitos fundamentais, e não sua restrição.

Isso sim se coaduna com a ideia de *meio menos gravoso* que fundamenta o princípio da proporcionalidade[10], eis que o deferimento da quebra de sigilo pelo Judiciário nenhuma lesão acarreta ao direito à intimidade e à privacidade, porque sufi-

[10] Explica Barbosa Moreira, acerca do princípio da proporcionalidade, que "Cabe verificar se a transgressão se explicava por autêntica necessidade, suficiente para tornar escusável o comportamento da parte, e se esta se manteve nos limites determinados pela necessidade; ou se, contrário, existia a possibilidade de provar a alegação por meios regulares, ou se a infração gerou dano superior ao benefício trazido à instrução do processo. **Em suma: averiguar-se do dois males, se escolheu realmente o menor**" (grifou-se). MOREIRA, José Carlos Barbosa. *A constituição e as provas licitamente adquiridas.* Ajuris n. 68, p. 15.

cientemente analisado, motivado, fundamentado, sempre *a priori*, enquanto que o fornecimento dessas informações diretamente aos órgãos de persecução penal, simplesmente porque assim requisitados, certamente violará, de forma irremediável, essa esfera de proteção.

Logo, o comando expresso no artigo impugnado compromete seriamente a esfera de proteção individual constitucionalmente assegurada em favor do usuário dos serviços de telecomunicações, cuja higidez igualmente compete às associadas da Autora legalmente zelar, sob pena de frontal desrespeito à Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que, em seu artigo 3º, inciso IX, estabelece o direito dos usuários dos serviços de telecomunicações "*ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora de serviço*"; à Lei nº 10.073/03, que estipula em seu artigo 1º, § 3º, a relação entre o sigilo dos dados dos usuários e a necessidade de autorização judicial para seu fornecimento; e à Resolução nº 426/05 da ANATEL, que aprovou o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado e estabelece a obrigação da prestadora de zelar pela confidencialidade dos dados e informações dos usuários.

Assim, inconteste que o sigilo dos dados de cadastro encontra guarida no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, porquanto traduzem informações da vida privada do cidadão e, portanto, devem gozar de garantia que impeça seu irrestrito devassamento. Nesse exato sentido, a lição do insigne professor Uadi Lammêgo Bulos: "*a princípio, os dados contidos nos bancos de informações também devem permanecer em segredo, para não violar a privacidade alheia*"[11].

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça comunga desse mesmo entendimento, como se depreende, a título de exemplo, do douto voto condutor do Acórdão proferido pela Terceira Turma nos autos do Recurso Especial nº 1.300.161/RS, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi:

> *"(...) ainda que muitos busquem na* web *o anonimato, este não pode ser pleno e irrestrito. A existência de meios que possibilitem a identificação de cada usuário se coloca como um ônus social, a ser suportado*

[11] *Constituição federal anotada*. 8ª ed. São Paulo, Saraiva, 2008, p. 159.

por todos nós objetivando preservar a integridade e o destino da própria rede.

Isso não significa colocar em risco a privacidade dos usuários. Os dados pessoais fornecidos ao provedor devem ser mantidos em absoluto sigilo *– como já ocorre nas hipóteses em que se estabelece uma relação sinalagmática via Internet, na qual se fornece nome completo, números de documentos pessoais, endereço, número de cartão de crédito, entre outros –* ***sendo divulgados apenas quando se constatar a prática de algum ilícito e mediante ordem judicial****"* (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.300.161/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.06.2012) – grifou-se.

No mesmo sentido, destacam-se os valorosos dizeres do eminente Ministro Massami Uyeda em voto proferido nos autos do Recurso Especial nº 1.068.904/RS:

"(...) ***o sigilo de dados tutelado, objeto de discussão, diz respeito também, na compreensão desta Relatoria, aos cadastros de dados*** *utilizados pela informática e, desse modo, o fornecimento deles a terceiros* ***depende de ordem judicial****.*

(...) Dessa forma, na verdade, bem de ver que não houve qualquer resistência da ora recorrente que, inclusive, na própria contestação (fl. 26), ***admitiu a possibilidade de fornecer os dados cadastrais, desde que mediante determinação judicial, sendo certo que não poderia ser compelida, extrajudicialmente, a prestar as informações à autora, ora recorrida, diante do sigilo constitucionalmente assegurado****"* (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.068.904/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 30.03.2011) – grifou-se.

Por fim, o valiosíssimo precedente de relatoria do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, sempre atual:

> *"RHC - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL PENAL - INFORMAÇÕES CADASTRAIS - SIGILO - Quando uma pessoa celebra contrato especificamente com uma empresa e fornece dados cadastrais, a idade, o salário, endereço. É evidente que o faz a fim de atender às exigências do contratante. Contrata-se voluntariamente. Ninguém é compelido, é obrigado a ter aparelho telefônico tradicional ou celular. Entretanto,* ***aquelas informações são reservadas, e aquilo que parece ou aparentemente é algo meramente formal pode ter consequências seríssimas****; digamos, uma pessoa, um homem, resolva presentear uma moça com linha telefônica que esteja no seu nome. Não deseja, principalmente se for casado, que isto venha a público.* ***Daí, é o próprio sistema da telefonia tradicional, quando a pessoa celebra contrato, estabelece, como regra, que o seu nome, seu endereço e o número constarão no catálogo; entretanto, se disser que não o deseja, a companhia não pode, de modo algum, fornecer tais dados.*** *Da mesma maneira, temos cadastro nos bancos, entretanto, de uso confidencial para aquela instituição, e não para ser levado a conhecimento de terceiros"* (STJ, Sexta turma, RHC 8493/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ 02.08.1999) – grifou-se.

Os ilustres Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, na esteira de nossas Cortes Superiores, também compartilham de semelhante orientação, conforme se depreende com exatidão dos seguintes precedentes, dentre inúmeros outros no mesmo sentido:

> *"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.* ***CADASTRO DE TELEFONIA MÓVEL.***

INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO MPF, MPE E POLÍCIAS. ***SIGILO.*** *ART. 5º, X A XIII, DA CF/88.* ***1. Os dados cadastrais dos usuários das operadoras estão protegidos pela garantia do sigilo, nos termos dos artigos 5.º, X a XIII, da CF/88 e 3.º, VI e IX, da Lei n.º 9.472/97, sigilo esse que somente pode ser quebrado mediante intervenção judicial, nas hipóteses cabíveis.*** *A entrega dos cadastros de todos os usuários dos apelantes aos solicitantes implicará a quebra do sigilo. 2. Embargos infringentes a que se nega provimento. (*TRF 4ª Região, Segunda Seção, EINF 0033295-12.2006.404.7100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJe 28.09.2012) – grifou-se.

"CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EMPRESAS DE TELEFONIA. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS CLIENTES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ***No caso de conflito entre o direito à privacidade do indivíduo consubstanciada no sigilo de seus dados cadastrais e a eficiência na atuação do MPF, principalmente na persecução penal, a solução para o citado conflito só pode ser dada diante de situação concreta e específica, e não mediante discussão abstrata sobre a prevalência de princípios****, sob pena de afastar a aplicação de um deles definitivamente, diminuindo seu campo de abrangência por meio de comando judicial que o Parquet pretende tornar imutável como efeito futuro da coisa julgada"* (TRF 2ª Região, Oitava Turma Especializada, AC 200851010116627, DJe 05.06.2012) – grifou-se.

*"****Os dados cadastrais dos usuários dos serviços de telecomunicações são protegidos pela inviolabilidade à pri-***

> ***vacidade, prevista no art. 5º, X, da Constituição da República.*** *(...) A prestação jurisdicional deve ocorrer com base em fatos concretos. A prolação de sentença desvinculada de situações específicas, a incidirem sobre fatos futuros, como se norma jurídica geral e abstrata fosse, não se compadece com a função jurisdicional. Por isso, a sentença não poderia ter determinado que as operadoras de telefonia informem os dados cadastrais de seus usuários em todos os casos que haja requisição formulada por membro do Ministério Público Federal ou de Delegado de Polícia Federal, e muito menos ter estabelecido, genérica e abstratamente, condições e procedimento para as requisições e a prestação das informações. -* ***Ao determinar que as operadoras forneçam os dados cadastrais dos seus clientes sempre que requisitados por membro do Ministério Público Federal ou de Delegado de Polícia Federal, a sentença acabou por transferir para essas autoridades a avaliação de quando o interesse na persecução penal deve prevalecer sobre o direito à privacidade de titulares de terminais telefônicos. Precedentes do STF reconhecendo que a mitigação de direitos fundamentais reconhecidos na Constituição somente pode ser realizada por órgãos com dever de imparcialidade, situação na qual o Ministério Público e as Polícias Judiciárias não se enquadram.*** *Ponderação entre os interesses de preservação do sigilo dos dados cadastrais e de eficácia da persecução penal reservada ao Poder Judiciário"* (TRF 5ª Região, Segunda Turma, AP 5397/SE, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto, DJe 01.12.2009) – grifou-se.

Portanto, a inconstitucionalidade material do artigo 17-B da Lei nº 9.613/98 é patente, eis que, não é demasia enfatizar, confere ao Ministério Público e às autoridades policiais o poder de diretamente requisitar – e, por conseguinte, às associadas da Autora, o dever de imediatamente prestar, com a supressão do Poder Judiciário –

informações resguardadas por sigilo, assim interferindo, indevidamente, na esfera de proteção fundamental dos usuários dos serviços de telecomunicações, sem que exista qualquer ponderação e avaliação judiciosa de *justa causa provável* a justificá-lo.

Ainda que hasteie o legislador ordinário a bandeira do combate à criminalidade econômica como pseudo-justificativa para tal intento, fato é que não se podem sobrepujar pura e simplesmente as balizas constitucionais com vistas a alcançar a todo custo o fim colimado, mormente em se tratando de direitos fundamentais. É assente na jurisprudência desta Egrégia Suprema Corte, como visto, que a relativização de direitos fundamentais, admitida somente em caráter excepcional, está condicionada à necessária apreciação judicial de *justa causa provável*, o que, portanto, se revela inviável sob um prisma abstrato.

Outrossim, saliente-se que o afastamento de direitos fundamentais, mormente no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não pode constituir ato de investigação inaugural, fulcrado em um mero *preceito de comodidade* em favor das autoridades investidas desse mister – essa é a verdadeira essência do artigo impugnado –, sobretudo quando claramente evidenciada a possibilidade de a informação almejada ser obtida por caminhos legais – judiciais – que sirvam precisamente a preservar as garantias constitucionais dos cidadãos, que, não se olvide, gozam da presunção de inocência.

Esse é, por exemplo, o espírito da Lei nº 9.296/96, que regulamenta os procedimentos de interceptação telefônica. Note-se que, em consistindo a medida uma inegável afronta ao direito constitucional à intimidade do cidadão investigado, optou o legislador à época, certamente mais afeto à preservação dos valores fundamentais da Constituição, por estabelecer critérios que justificassem sua incidência somente nas hipóteses em que reputada absolutamente indispensável, ou seja, quando a prova não pudesse ser feita por outros meios disponíveis. Ademais, ainda circunscreveu-a estritamente aos casos de crimes punidos com reclusão e desde que presentes indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, requisitos estes, frise-se, cuja presença compete exclusivamente ao Judiciário avaliar e, por conseguinte, decidir se suficientes à flexibilização de importantíssima e vital garantia à preservação de um Estado não policialesco.

Trata-se, evidentemente, de postura legal garantista, que privilegia os valores constitucionais, o que, entretanto, não é óbice (como alguns querem fazer crer) à sua efetiva aplicação. Tanto é que inúmeras foram as condenações que se sustentaram sobre as provas por esse meio obtidas.

O artigo 17-B da Lei nº 9.613/98, entretanto, cria premissas completamente distintas, eis que institui um inadmissível *preceito de comodidade*, que, sob falacioso discurso permeado por palavras bem polidas como *celeridade*, *efetividade*, *eficiência* – conforme confessado no relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal –, segrega do Poder Judiciário o poder-dever de examinar caso a caso se a flexibilização do direito fundamental à privacidade se justifica, transferindo-o ao Ministério Público e às autoridades policiais, que são parte na investigação, e que, por óbvio, têm, muito estranhamente, restrições em submeter a medida ao prudente crivo do Judiciário.

Todos sabemos que é mais fácil e rápido arrancar de alguém uma confissão mediante tortura. Alguns até dirão que os fins justificam os meios. Contudo, essa *comodidade* não está acima dos pilares constitucionais sobre os quais se assenta todo o ordenamento jurídico pátrio. Se há meios de se obter os dados pessoais dos cidadãos por via segura, que privilegie seus direitos fundamentais, é por esse – do qual é dever inalienável do Judiciário ser seu guardião – que se deve seguir. O artigo impugnado segue por outro, paralelo, que margeia a lei e a Constituição Federal, pelo que não se pode admiti-lo.

A corroborar esse entendimento, são novamente oportunos, como sempre, os valorosos dizeres dos Preclaros Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, *in verbis*:

> "*(...)* ***os fins não justificam os meios****. Há parâmetros ético-jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado.* ***Os órgãos do Poder Público, quando investigam, processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitarem os estritos limites da lei e da Constituição****, por mais graves que sejam os*

> *fatos cuja prática motivou a instauração do procedimento estatal*" (STF, Tribunal Pleno, MS 23619-DF, voto do Min. Celso de Mello em acórdão de relatoria do Min. Octávio Gallotti, DJU 07.12.2000) – grifou-se.
>
> "*É hora de dar-se concretude aos ditames constitucionais, pagando-se, assim, o preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito.* ***Jamais é demasia frisar-se que, em Direito, o meio justifica o fim, mas não este aquele***" (HC 84038, Rel. Min. Marco Aurélio, Decisão monocrática publicada no DJU de 01.07.2004) – grifou-se.

Finalmente, é preciso consignar que alguns menos avisados – ou talvez completamente desavisados –, pretendam sustentar a ideia, absurda, de que o direito fundamental à privacidade do cidadão não está sob a égide da tutela jurisdicional, mas, tão somente, a intimidade dela gozaria.

Ora, tal despautério é, nada mais, nada menos, que a deturpação do texto claro de nossa Constituição Federal, pois tanto a privacidade quanto a intimidade são estruturas que compõem uma única e mesma célula de proteção fundamental, sendo esta o núcleo que aquela outra envolve. Assim, outra não pode ser a conclusão de que ambas são verdadeiramente dignas de tutela jurisdicional: a privacidade, sob um prisma judicial *lato sensu*, cujo afastamento pode ser determinado por Juízos de diversas áreas do Direito (civil, criminal, tributária etc.), ao passo que a intimidade encontra amparo judicial *stricto sensu*, cuja regulamentação, ao detalhe, foi alcançada pela Lei nº 9.296/96, conforme vimos.

Logo, claro está, conforme se depreende da leitura do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que não há guarida para as temerárias alegações de que o direito fundamental à privacidade não está sujeito *à cláusula tutelar de reserva constitucional*, como linhas acima bem consignou o Preclaro Ministro Celso de Mello.

Por conseguinte, é de rigor o cabal reconhecimento da efetiva inconstitucionalidade material do artigo 17-B da Lei nº 9.613/98, incluído pela Lei nº 12.683/2012, pois somente o Poder Judiciário pode eximir as empresas de telefonia do dever que lhes incumbe de preservar o sigilo dos dados de cadastro de seus usuários.

IV – DO PEDIDO CAUTELAR

Diante de todo o exposto, resta claro que o artigo cuja inconstitucionalidade ora se argui realmente padece de grave vício material, haja vista as premissas constitucionais alhures mencionadas, e que, por se encontrar em plena vigência – a Lei nº 12.683/12 entrou em vigor na data de sua publicação, que se deu em 10 de julho de 2012 –, está a exigir sua observância imediata por parte das associadas da Autora, sob os riscos de incorrerem seus representantes em crime de desobediência em caso de recusa, além de colocar em perigo a preservação de direitos fundamentais de todos os usuários dos serviços de telecomunicações. Assim, faz-se urgente e imperiosa a concessão do socorro cautelar.

Para tanto, evidente o *fumus boni iuris*, pois firme a jurisprudência dessa Egrégia Corte quanto à inadmissibilidade da subversão dos valores fundamentais positivados na Constituição Federal, mormente dos salutares direitos à intimidade e à privacidade que imunizam o cidadão contra os desmandos arbitrários do poder, cuja relativização somente pode ser ordenada pelo Poder Judiciário ante a existência de *justa causa provável.*

Ademais, densificada está a fumaça do bom direito pela decisão já proferida por essa Egrégia Corte nos autos do RE 389.808/PR, cujos fundamentos aplicam-se perfeitamente ao caso em escólio.

Outrossim, presente o *periculum in mora*, na medida em que as associadas da Autora e seus representantes encontram-se atualmente compelidos a adequar-se a regras que se sabe, desde o princípio, claramente inconstitucionais, além de estarem sujeitos à responsabilização civil e criminal em caso de desobediência.

Portanto, nos termos do artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, requer-se a Vossa Excelência, dada a excepcional urgência, o deferimento da medida cautelar ora postulada, *sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado,* para suspender a vigência do artigo 17-B da Lei nº 9.613/98, até final julgamento da presente ação.

V – DO PEDIDO MERITÓRIO

No mérito, requer-se, após a prestação de informações pelo Congresso Nacional e pela Presidente da República, e após a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, seja julgada procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 17-B da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, acrescido pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2013.

David Rechulski
OAB/SP 106.067

Ricardo Pagés
OAB/SP 266.986